

1509443-04.2021.8.26.0344

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... 263,00. O réu confessou a prática do tráfico. Ele já era conhecido dos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico, inclusive quando era menor de idade.

O réu Kaio Luan Mendonça Gonçalves, interrogado, informou que mora no CDHU e na data dos fatos estava na frente de casa com a mãe e a filha. Ele foi abordado pela polícia e, como era usuário de crack e conhecido dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1509443-04.2021.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1509443-04.2021.8.26.0344

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAIO LUAN MENDONÇA GONÇALVES

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

KAIO LUAN MENDONÇA GONÇALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, no dia 29 de setembro de 2021, por volta das 20h30min, na Rua Mario Bataiola, 501, em Marília/SP, para fins de tráfico, 116 (cento e dezesseis) invólucros plásticos, contendo Tetrahydrocannabinol (THC), com massa líquida de 547 gramas, além de 69 (sessenta e nove) microtubos plásticos, contendo cocaína, com massa líquida de 18 gramas, substâncias entorpecentes que determinam dependência psíquica e que constam da Portaria 344/1998 SVS/MS, conforme auto de apreensão exibição de fls. 13/14, laudo pericial de constatação de fls. 21/22 e laudo definitivo de fls. 85/88.

Preso em flagrante delito, houve a conversão em prisão preventiva (fls. 59/61). O réu foi notificado e citado (fl. 120 e fl. 192) e apresentou sua defesa preliminar (fls. 152/154). A denúncia foi recebida em 17/1/2022 (fls. 162/165). Na audiência virtual, realizada em 27/1/2022, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum e o réu foi interrogado (fls. 193/194).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Na fixação da pena, deverá ser considerado que o réu foi condenado recentemente em outro processo (embora a condenação não seja definitiva), bem como já foi condenado por atos infracionais quando menor. Desta forma, inviável o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. O regime inicial deve ser o fechado e são incabíveis quaisquer benesses legais.

A Defesa do réu, em alegações finais, requereu a sua absolvição por não estarem presentes indícios suficientes de autoria. Não havia no local outras pessoas e não foi realizada campanha pela polícia, que pudessem assegurar que o réu iria vender o entorpecente. Dessa forma, o réu deve ser absolvido ou o delito desclassificado para o do art. 28 da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, em caso de condenação, as penas devem ser fixadas no mínimo, com o reconhecimento do privilégio, e o regime inicial deve ser o aberto, com a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

É o relatório. DECIDO.

A acusação é procedente.

A existência material do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, isto é, a realização do tipo penal em todos os seus elementos, restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 4), boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), pelos laudos de constatação e de exame químico-toxicológico (fls. 21/22 e 85/88), este último atestando a natureza da substância apreendida (tetrahidrocannabinol / cocaína), pelo relatório final da D. Autoridade Policial (fls. 90/91) e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa.

As testemunhas Ewerton Leite Lamarca e Derek Suichi dos Santos Sakano, policiais militares, declararam que na data dos fatos estavam em patrulhamento pela zona sul da cidade. Quando se aproximaram do CDHU, em local conhecido como ponto de venda de drogas, avistaram o réu, sozinho, com três sacolas na mão. Decidiram abordá-lo e ele, quando viu a viatura, tentou fugir, sendo necessário o uso de força moderada para detê-lo. Ao revistarem as sacolas que ele trazia nas mãos, foram encontradas 69 "pinos" de cocaína, 116 porções de maconha e R\$ 263,00. O réu confessou a prática do tráfico. Ele já era conhecido dos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico, inclusive quando era menor de idade.

O réu Kaio Luan Mendonça Gonçalves, interrogado, informou que mora no CDHU e na data dos fatos estava na frente de casa com a mãe e a filha. Ele foi abordado pela polícia e, como era usuário de crack e conhecido dos policiais, permaneceu detido. Outro rapaz que estava no local foi abordado e com ele foram encontradas porções de entorpecente. Contudo, este rapaz foi liberado e a propriedade da droga foi atribuída a ele.

Apesar da negativa do réu, da prova oral coligida, reputo existirem elementos bastantes que demonstram que ele era o proprietário do entorpecente e que as porções apreendidas se destinavam ao tráfico ilícito de drogas, nos termos do art. 52, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da ocorrência concomitante das seguintes circunstâncias: a) o fato do acusado ser avistado em local conhecido pelo tráfico de drogas, com sacolas plásticas nas mãos, empreendendo fuga tão logo notou a presença dos policiais; b) a quantidade e natureza das drogas apreendidas, acondicionadas e embaladas individualmente (foto de fl. 15), certamente destinadas à comercialização; c) a quantia de dinheiro apreendida com o réu, em notas diversificadas, boa parte de pequeno valor, como é comum nas apreensões do comércio de drogas, dinheiro cuja origem lícita não foi comprovada nos autos.

A versão apresentada pelo acusado de que somente foi detido porque sendo usuário é conhecido pelos policiais, e que as porções de droga estariam na posse de terceira pessoa que foi liberada, restou isolada nos autos, não havendo qualquer elemento que dê suporte a eventual suspeita de que os policiais tenham algum interesse em incriminar falsamente o réu.

Ademais, ao contrário do que aduz a Defesa, a acusação encontra respaldo probatório nos autos, já que os relatos dos policiais foram harmônicos no sentido de que avistaram o réu com sacolas plásticas nas mãos, em local conhecido pelo tráfico de drogas e, após a abordagem, localizaram os entorpecentes e a quantia em dinheiro.

Outrossim, em que pese a combativa Defesa argumentar que a conduta deve ser desclassificada para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (artigo 28 da Lei nº 11.343/2006), não faz prova de que a droga destinava-se para o uso do réu, tese sustentada tão somente no relato por ele ofertado.

Não há nos autos qualquer outro elemento, como por exemplo, registro de que o réu tenha sido submetido a tratamento para dependentes químicos, que sustente a tese defensiva. Outrossim, o acusado disse em Juízo ser viciado em "crack", contudo, estava na posse de maconha e cocaína. E mesmo que o réu seja usuário, tal fato, por si só, não afasta de forma automática a traficância, pois nada impede que ele faça uso de entorpecente e também venda drogas a terceiros.

Além disso, não é crível que sendo mero usuário estivesse em local conhecido pela venda ilícita de entorpecentes, arriscando-se como ocorreu a sofrer uma abordagem policial, com grande quantidade de entorpecente.

Por fim, o fato de não ocorrer campana prévia e de o réu não ser flagrado no exato momento em que entregava droga para a venda a terceiros não altera os fatos, vez que o tráfico ilícito de entorpecente é delito de conteúdo alternativo, bastando para a sua configuração a prática de quaisquer das condutas descritas no preceito primário da norma.

Portanto, denota-se pela prova coligida que houve a completa subsunção da conduta do réu ao tipo do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Reputo, assim, que há prova robusta e suficiente para um decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição.

Com relação à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, destaco a impossibilidade de aplicação na situação em tela. Verifico que, além da quantidade e da nocividade dos entorpecentes apreendidos, conforme consta nos documentos de fls. 125/129 e 130/132, o réu ostenta antecedentes infracionais e, inclusive, cumpriu medida socioeducativa de internação por atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes. Embora tais feitos da Vara da Infância e Juventude não permitam a valoração negativa na primeira fase da dosimetria ou signifiquem reincidência (artigos 59 e 64 do Código Penal c/c Súmula 444 do STJ), são dados idôneos para afastar a minorante, porquanto comprovam a dedicação às atividades delituosas desde a adolescência e a habitualidade em praticar fatos tipificados como crime. Nesse sentido:

Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Inaplicabilidade da redutora do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas em razão da dedicação do acusado às atividades criminosas, conforme atos infracionais praticados quando adolescente. Precedentes do STJ. Substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Recurso improvido. – Apelação nº 1500768-90.2020.8.26.0472, Rel. Reinaldo Cintra, 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 28/2/2021.

"(...) Considerando que um dos requisitos para concessão da benesse é o agente não se dedicar a atividades criminosas, é certo que o envolvimento do paciente quando menor em atos infracionais, inclusive relacionados ao crime de tráfico, é elemento idôneo a afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demonstra uma propensão do agente a práticas criminosas (...)" - AgRg no HC 560.742/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T., DJe 04/05/2020.

"(...) A existência de registros de atos infracionais é apta a justificar a negativa da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, por indicar a dedicação do réu à prática delituosa, nos moldes admitidos pela jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, inexistindo ilegalidade a ser sanada quanto ao ponto (...)" - AgRg no HC 544.100/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 14/02/2020.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a Lei nº 11.343/2006 prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e a previsão do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa porque apesar da quantidade e natureza do entorpecente, o réu é primário (fls. 37/38). A culpabilidade, entendida como a reprovabilidade da conduta, não ultrapassa o normal desvalor do crime. Além disso, como mencionado, o réu é primário e não há nos autos elementos que lhes sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem a majoração da pena-base.

Na segunda fase, não há circunstância agravante a ser ponderada. Verifico que incide a atenuante prevista no artigo 65, incisos I, do Código Penal, porque o réu era menor de 21 anos de idade na data dos fatos (fl. 23). Contudo, não pode reduzir a pena abaixo do patamar mínimo legal.

Não há causas de aumento de pena. Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois a quantidade expressiva e a natureza da droga encontrada em seu poder, bem como a quantia em dinheiro e os registros na Vara da Infância, inclusive por atos infracionais análogos ao tráfico ilícito de entorpecentes, não havendo qualquer prova de atividade laborativa lícita, indicam que o acusado se dedica a atividade criminosa, inviabilizando a aplicação do redutor.

Mantenho, desta forma, a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Pelas condições econômicas do réu, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO KAIO LUAN MENDONÇA GONÇALVES, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial fechado em razão da gravidade do delito, crime equiparado a hediondo e em virtude da quantidade e da natureza de parte da droga apreendida (cocaína), conhecida por seu alto poder

destrutivo. Além disso, verifico que, nos termos do § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, mesmo que computado o tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, ainda assim o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, por não ter atingido o lapso de tempo necessário para progressão de regime.

Anoto que, diante da pena fixada, é inviável a sua substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme art. 77 do mesmo diploma legal.

O réu teve a prisão preventiva decretada logo após sua prisão em flagrante com quantidade expressiva de entorpecentes, de nefasta repercussão social, permanecendo encarcerado durante o curso do processo, restando claro que persistem as razões que ensejaram sua custódia cautelar, fortalecidas agora pela sentença condenatória. Destarte, mantenho a prisão preventiva do réu, que não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

A negativa do direito de recorrer em liberdade no parágrafo acima, considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar, significa a inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno a partir da presente data.

Recomende-se o réu no presídio em que se encontra recolhido.

Em face da condenação supra, o sentenciado arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs. Todavia, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade permanecerá sobrestada.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Ademais, conforme o art. 91, inciso II, do Código Penal, c/c o art. 63, da Lei Federal 11.343/2006, coadunados com o Tema 647 de Repercussão Geral do Excelso Pretório (REX 638.491, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 17/05/2017), que estabelecem que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão revertidos em favor da União, decreto o perdimento do bem, consistente no depósito judicial de fl. 89.

Cobre-se a multa e a taxa judiciária, se forem devidas, de acordo com as NSCGJ.

Para se evitar, ao menos por ora, a intimação pessoal do sentenciado, dê-se vista imediatamente ao Ministério Público e intime-se a Defesa pelo DJE, a fim de que se manifestem acerca de eventual recurso.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Marília, 2 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA